

1500091-88.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... já que a condenação anterior também é por tráfico.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500091-88.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500091-88.2022.8.26.0537 Controle nº 50/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TULIO GOMES LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

TÚLIO GOMES LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 15:35 horas, na Travessa Beirute, altura do número 10, Bairro Taboão, adquiriu e trazia consigo, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 34/37).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 77/78), sendo recebida a denúncia em 15.03.22 (fls. 83/84). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas e pela agravante da reincidência, fixação de regime fechado, que seja afastada a aplicação do art. 33, §4.º por ser reincidente e o perdimento do dinheiro apreendido.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, que seja considerada a confissão informal para os policiais, a fixação de regime semiaberto diante da detração penal.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o acusado negou a prática do crime e a posse das drogas (fls. 08). Disse que estava bebendo com outros homens em frente a casa. Falou que sabia que o local é ponto de venda de drogas, por isso correu ao ver a viatura. Informou possuir duas condenações criminais, uma por tráfico, do ano de 2015, e outra por roubo, de 2017. Falou que atualmente está com a vida "certinha", trabalhando como técnico em eletrônica com o pai. Informou não ter filhos.

Em juízo, afirmou que estava com a namorada na adega, bebendo cerveja. Narrou que foi até a casa de sua avó para ver se esta estava bem, voltou para a adega, onde ficou sua namorada e foi abordado. O policial pediu dinheiro e como não tinha, voltaram com a pochete na mão e o incriminaram. Trabalhava com seu pai com eletrônica. Tem condenações por tráfico e roubo. Não conhecia os policiais militares, nem os policiais civis da delegacia. Havia diversas pessoas na adega e sua namorada também viu a abordagem policial. Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que em patrulhamento avistaram o réu sozinho na via pública, em local conhecido como ponto de tráfico. Relataram que ao se deparar com a viatura o réu dispensou uma bolsa pequena que trazia nas mãos e saiu correndo. Narraram que o policial Paulo desceu da viatura e correu atrás do réu, enquanto o policial Thiago fez a volta na quadra com a viatura, ficou de frente com o réu e o abordou. Falaram que o policial Paulo apanhou a bolsa dispensada pelo réu. Afirmaram que encontraram drogas, divididas em pequenas porções, individualmente embaladas. Declararam que em revista pessoal localizaram a quantia de R\$ 21,00 em poder do réu.

Paulo (policial), em juízo, informou que o local é conhecido como ponto de tráfico, o réu estava com uma sacola bege na mão, a dispensou, correu e foi abordado. Havia dinheiro em poder do réu. Na sacola dispensada havia drogas (várias porções de maconha, "crack" e cocaína). O réu confessou informalmente, mas na delegacia negou. O réu estava sozinho, parado na viela com a sacola na mão, viu a equipe, dispensou esta e correu. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Thiago. Esclareceu que foi o seu parceiro que abordou o réu e ele fez a volta com a viatura e o revistou. Informou que em poder do réu só havia dinheiro e na pochete dispensada tinha várias porções de drogas (crack, maconha e cocaína). Não conhecia o réu.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 11 - 38 invólucros de cocaína, 10 pedras de "crack" e 99 porções de maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o

tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade e variedade se não fosse traficante.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir e trazer consigo.

A alegação do réu de que estava apenas consumindo bebida alcoólica no local e que não estava com drogas está isolada nos autos, posto que alegou, mas nada provou como lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 22/25) e laudo definitivo (fls. 54/56). Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 27 – proc. 2145-77.2017 e proc. 6524-93.2015).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (fls. 11 - 38 invólucros de cocaína, 10 pedras de "crack" e 99 porções de maconha, já que pequena quantidade em Diadema é inferior a 100 porções), em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Aumento a pena de 1/6 pela reincidência. A confissão informal para os policiais não caracteriza a atenuante, na medida que não confirmada, quer na fase extrajudicial, quer em juízo.

O réu não faz jus à redução do art. 33, §4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que a condenação anterior também é por tráfico. Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art.

33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é duplamente reincidente, inclusive específico (fls. 27 – proc. 2145-77.2017 e proc. 6524-93.2015), o que denota personalidade voltada para crimes, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita, o que demonstra que o tráfico é seu meio de vida e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz

natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em , pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência, inclusive específica (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO TÚLIO GOMES LIMA à pena de 6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou ocupação lícita nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Em relação à bolsa tipo "tiracolo" com inscrição "Louis Vuitton Paris", apreendida (fls. 11) e já periciada (fls. 57/58), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada.

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 51 e 70 - R\$ 21,00) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 40) e providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 30 de março de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA